

1500268-49.2021.8.26.0614
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 20/05/2022
... da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500268-49.2021.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500268-49.2021.8.26.0614
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219177/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 19592971 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 87/21/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2219177 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ANTONIO ISAAC CORDULINO DA SILVA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

Antônio Isaac Cordolino da Silva e João Pedro do Amaral Isolato, qualificado nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em data inicial não sabida, decerto no início de 2021, permanecendo de forma estável e permanente até 12 de agosto de 2021, neste município e comarca, os réus, junto com o adolescente Maicon Jhonatan de Oliveira, associaram-se entre si para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de nº

11.343/2006 (1º Fato). Ainda, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 17h20min, em via pública na Rua Antônio Fabricante, Bairro Jardim Pontal das Pitas, próximo ao “Bar do Ceará”, os dois réus e o menor Maicon tinham em depósito, visando à mercancia ilícita, 01 tijolo de maconha (197,22g.), 12 pedras de crack (1,37g.), 07 pinos de cocaína (4,36g.) e 01 porção de maconha (0,51g.), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar (2º Fato).

Consta da denúncia que o trio vem praticando a traficância na comarca, tendo se associado entre si de forma estável e permanente. Segundo consta, utilizavam uma Kombi abandonada nas proximidades com o primeiro esconderijo e local onde as drogas adquiridas inteiras pelo grupo eram fracionadas e após o preparo das substâncias, contavam com outro abrigo para as substâncias em menores quantidades, que era uma sarjeta em via pública. À medida que vendiam essas drogas, os denunciados voltavam para esses locais para recolher mais substâncias e retornavam ao ponto para comercializá-las, revezando entre eles essas tarefas.

Ainda nos termos da inicial acusatória, com várias denúncias anônimas, o trio passou a ser monitorado, sendo que em diligências veladas, ANTÔNIO, JOÃO e o MAICON foram visualizados enquanto comercializavam as substâncias. Foram vistos ainda buscando substâncias junto a uma sarjeta na rua, entre as folhas secas de um arbusto. Abordados, com eles nada foi encontrado. Contudo, em buscas no local onde revisitavam para recolher as substâncias, foram encontradas 12 pedras de crack, 07 pinos de cocaína e 01 porção de maconha. Ato contínuo, na Kombi abandonada, entre os pneus, foi encontrado um tijolo não fracionado de maconha.

Defesa preliminar apresentada pelos réus (fls. 122/126).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2022, as 13:30. (fl. 133/134)

A denúncia foi recebida em audiência. Sendo os réus citados no ato. Após, foram ouvidas testemunhas e ao final os réus foram interrogados.

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência, anotando que não há prova da associação para o tráfico. Requer o afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

A defesa, ao seu turno, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva. aponta inexistir prova suficiente para a condenação. pugna pela revogação da prisão preventiva.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa aos réus a prática do crime previsto no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de

drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública. O artigo 35, do mesmo diploma legal, possui a seguinte redação:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Para a prática deste tipo legal, basta que haja associação de duas pessoas, contudo, exige-se que este ajuste não seja eventual, mas ao contrário, que hajam elementos que denotem a permanência e estabilidade.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl.1), auto de exibição e apreensão (fl. 38/39), auto de constatação preliminar (fls. 41), boletim de ocorrência (fls. 35/37), laudo pericial (fls. 92/94), laudo pericial do aparelho celular (fls. 95/101), além da prova oral produzida.

A testemunha César Augusto Seridônio, Policial Civil, disse que recebeu denúncia anônima acerca da traficância, decidindo montar campana. Disse que a droga estava no meio fio, que havia uma kombi onde guardavam a droga. Disse que montaram a campana e conseguiram confirmar a prática do tráfico de droga. Indicou a quantidade de droga apreendida. Na kombi encontrou entre pneus um tablete de maconha de quase duzentos gramas. Disse que não foi possível fazer a abordagem dos usuários em virtude da distância, pois seriam identificados pelos réus. Disse que receberam denúncias indicando os responsáveis. Disse que os três revezavam o crime. Conta que visualizou que os usuários aproximavam dos réus, os quais saíam e se abaixavam em um local, onde posteriormente foi encontrada a droga (meio-fio entre folhagens), e depois retornavam ao usuário, recebendo algo em troca. Conta que não viram os réus se dirigindo até a kombi. Disse que estavam em cinco pessoas na operação. Disse que não localizaram usuários ou outras testemunhas. Disse que já havia realizado flagrante no local. Não soube precisar se algum dos réus estava de bicicleta. Disse que com os réus nada foi encontrado.

A testemunha de defesa, Letícia Samara de Siqueira, disse que não presenciou a prisão dos réus. disse que não estava próxima do local da prisão. disse que trabalhou junto com o réu em um engenho, que não sabe de envolvimento com drogas. Antônio Isaac Cordulino da Silva, ao ser interrogado, disse que a acusação não é verdadeira. Conta que é morador do bairro, disse que trabalha próximo do local e no dia não havia ido trabalhar em virtude de chuva. Conta que a tarde estava de bicicleta, indo para a casa do sogro, que ao se aproximar do local, viu os policiais algemando o Maicon e o João Pedro. Disse que conhece o menor. Conta que

foi parado pelos policiais e eles estavam revirando o mato, que não tinha droga nem dinheiro. Disse que os policiais pediram ao réu para assumir a posse da droga. Que conhece o João Pedro de vista, que a esposa é amiga da esposa do outro réu. Disse que estava passando no local, tendo avistado que Maicon e João Pedro havia sido algemado. Disse que não tem celular, conta que no local havia outras pessoas. João Pedro do Amaral Isolato, em seu interrogatório, disse que estava próximo da mercearia do Ceará, quando foi abordado pela polícia. disse que foi algemado. disse que não é conhecido por gordinho. disse que estava a cerca de 100 metros do local onde a droga foi apreendida.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl.1), auto de exibição e apreensão (fl. 38/39), auto de constatação preliminar (fls. 41), boletim de ocorrência (fls. 35/37), laudo pericial (fls. 92/94 e 95/101), além da prova oral produzida.

Foram encontrados 01 tijolo de maconha (197,22g.), 12 pedras de crack (1,37g.), 07 pinos de cocaína (4,36g.) e 01 porção de maconha (0,51g.).

A autoria restou parcialmente comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1) e pela prova oral produzida em audiência.

Há certa dificuldade na confirmação da autoria, notadamente em virtude da insuficiência probatória.

A prova dos autos encontra-se subsidiada apenas pelo depoimento pessoa do policial civil César Augusto Seridônio, o qual narra a existência de droga em uma Kombi abandonada, sem que tenha visto os réus se dirigirem até o local. Destaco que ao menos em outros três processos de outros réus há referência a Kombi e ao armazenamento de droga em seu interior. Não é possível imputar aos réus a propriedade da droga encontrada na Kombi.

Narra o policial civil que os réus e o adolescente estaria negociando a droga com usuários, armazenando pequena quantidade de droga na sarjeta, próximo onde a droga era negociada. Ocorre que não há descrição clara o suficiente de quais foram os atos praticados por cada réu, aponta que eles se revezavam, contudo, há certa vagueza na afirmação.

A operação teria sido realizada por cinco agentes. O depoente afirma que havia várias pessoas no local, inclusive usuários, não tendo sido identificado qualquer destes. O local da abordagem é próximo de um bar, também não tendo sido identificada qualquer pessoa no local.

Consigno que tampouco foi encontrado qualquer quantia em dinheiro, apesar da grande movimentação de usuários, como narrado pelo depoente.

A única prova capaz de confirmar a autoria de Antônio Isaac Cordulino da Silva é o laudo de fls. 95/101 referente a apreensão de seu aparelho telefônico. Extraí-se do documento a existência de diálogos com terceiros com clara indicação da comercialização da droga (tô quase abrindo a biqueira... Tô trampando mas um pouco para cima... Tô querendo arrumar abrir essa biqueira de novo), além de ter enviado foto de drogas para terceiro.

As mensagens não foram trocadas com João Pedro, tampouco com indivíduos com codinome ou apelidos que o referencie. Não há, nas conversas, qualquer indicação da participação de João Pedro.

Em relação a Antônio Isaac, ao contrário, os elementos são incriminadores, estando em congruência com o depoimento policial. Assim, a autoria encontra-se demonstrada apenas em relação a Antônio Isaac Cordulino da Silva.

Pois bem, diante disso, considerando os elementos amealhados, verifico que a quantidade da droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

Assinalo que Isaac não possui condenação transitada em julgado, portanto, primário. Não há prova de que integre organização criminosa ou que se dedique a prática de crimes. Portanto, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Observo que a quantidade e diversidade da droga localizada [12 pedras de crack (1,37g.), 07 pinos de cocaína (4,36g.) e 01 porção de maconha (0,51g.)] autoriza a aplicação de menor redutor, razão pela qual reduzo a pena em 1/2. Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado, Antonio Isaac Cordulino da Silva era, na data dos fatos, imputável, tinham plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa. Portanto, culpável. Em relação a João Pedro do Amaral Isolato, conforme apontado, não há prova da sua participação, devendo ser absolvido.

A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

DO RÉU ANTONIO ISAAC CORDULINO DA SILVA

A culpabilidade é normal a espécie. Não há maus antecedentes a serem valorados. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga justificam maior exasperação, contudo será utilizado para influir na diminuição da pena (art. 33, §4º, do CP), não devendo incidir em duplicidade. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Segunda etapa. Ausentes agravantes e atenuantes.

Terceira etapa. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, reduzindo-se em 1/2, diante da diversidade, quantidade e natureza da droga.

Fixo a pena base em 2 anos e 5 meses de reclusão e 250 dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO

Diante do montante da pena arbitrada, determino seu cumprimento inicial no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, b do CP.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): POSSIBILIDADE.

As circunstâncias judiciais indicam a POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direito. A pena aplicada é inferior a

quatro anos, não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não é reincidente em crime doloso. Destarte, tratando-se de condenação superior a um ano, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Considerando a inexistência de local para cumprimento da medida nesta Comarca, o acusado deverá permanecer em sua residência, no período das 20:00 horas de sábado até as 06:00 horas de domingo, bem como das 20:00 horas de domingo até as 06:00 horas de segunda-feira, convertendo-se a limitação de final de semana em interdição temporária de direitos.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado. Não há elementos seguros o suficiente para a detração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ANTONIO ISAAC CORDULINO DA SILVA pelo crime previsto no artigo 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 2 anos e 5 meses de reclusão e 250 dias-multa, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

ABSOLVO o réu JOÃO PEDRO DO AMARAL ISOLATO da prática do crime previsto no artigo 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de prova da sua participação, nos termos do art. 386, V, do CPP, e ABSOLVO o réu ANTONIO ISAAC CORDULINO DA SILVA da prática do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Conforme pacífica Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive nos termos do HC 181.534, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, publicado em 02/03/2020, "eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias".

Em igual sentido:

'PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário' (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).

Com maior razão na hipótese de condenação ao regime aberto.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva revela violação ao princípio da homogeneidade.

Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA dos Réus, determinando a imediata expedição dos alvarás de soltura.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida,

com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA